

1500324-51.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paolo Pellegrini Junior

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 3,05 gramas, e 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 0,62 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, Henrique promovia o tráfico de drogas na cidade de Iacri, o que já era de conhecimento nos meios policiais. Na data dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500324-51.2021.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500324-51.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2329895/2021 -

DEL.POL.IACRI, 264/2021 - DEL.POL.IACRI, 51/2021 - DEL.POL.IACRI, 2329895 -

DEL.POL.IACRI, 264/21/403 - DEL.POL.IACRI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Paolo Pellegrini Junior

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA, denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 21h55, na Rua Avenida Jurema, nº 1.225, Centro, cidade de Iacri, Comarca de Bastos, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 3,05 gramas, e 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 0,62 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, Henrique promovia o tráfico de drogas na cidade de Iacri, o que já era de conhecimento nos meios policiais. Na data dos fatos, ele trazia consigo, 04 porções de cocaína, acondicionadas na forma de "travesseiro", e 01 cigarro de maconha, prontos para a venda, quando foi abordado por policiais militares.

Em revista pessoal, os policiais encontraram em uma das mãos do denunciado 02 porções de cocaína e, no interior de sua carteira, mais 02 porções de cocaína, 01 cigarro de maconha e a quantia de R\$ 52,00.

A quantidade, a diversidade, a natureza, as informações pretéritas ligadas ao

comércio de entorpecentes e as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o denunciado praticava tráfico de drogas.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Boletim de ocorrência (fls. 07/09).

Auto de exibição e apreensão (fls. 17/18).

Fotografias (fls. 19/20).

Laudo pericial de constatação (fls. 22/24).

Decisão de fls. 56/58 converteu a prisão em flagrante em liberdade provisória.

Relatório final (fls. 77/78).

Laudo pericial definitivo (fls. 86/90).

Notificado (fls. 105), o denunciado apresentou defesa prévia (fls. 111/112).

A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2022 (fls. 115/116).

Designou-se audiência de instrução para esta data, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

O Ministério Público, nos debates, postulou a condenação do réu pela prática do tráfico, com a redução máxima do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, a seu turno, sustentou ser o caso de desclassificação do delito para a figura do artigo 28 da Lei n.º 11343/2006.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, fotografias de fls. 19/20, laudo provisório de fls. 22/24 e laudo definitivo de fls. 86/90, bem como na prova oral colhida nesta data.

A autoria, de forma extrema de dúvidas, recai sobre a pessoa do acusado. Vejamos.

A testemunha comum José Luis Nicolau, policial militar, em juízo, disse que estava em patrulhamento pela avenida Jurema. O acusado foi avistado e na mão dele já constava dois papérols de cocaína. Na carteira tinha mais dois papérols e um cigarro de maconha parcialmente consumido e R\$ 52,00 em dinheiro. O réu mencionou que a droga era destinada à venda numa festa que ocorria no distrito industrial naquela noite. Havia notícias da polícia civil de que o réu estava envolvido com o tráfico e que já haviam realizado busca domiciliar na residência dele. O réu não esboçou reação quando foi abordado. Cooperou com a abordagem, sem tentar fuga. No momento da apreensão não houve menção pelo réu ser usuário de drogas.

A testemunha comum Luciano Cortez Fernandes, policial militar, em juízo, disse que estava em patrulhamento pela avenida Jurema e avistou o réu. Ele tinha algo em mãos. Foi abordado por haver notícias de que estava envolvido com o tráfico. Nas mãos, trazia duas porções de cocaína. Na carteira, havia outras duas porções de cocaína e um cigarro de maconha. Houve apreensão de R\$ 52,00 em dinheiro. Disse o réu que a droga era destinada à venda numa "balada" que teria no distrito industrial de Iacri. As notícias do envolvimento do réu com o tráfico vinham de usuários abordados, que diziam ter comprado dele. O cigarro de maconha estava parcialmente consumido. O réu mencionou ser usuário de maconha.

O acusado Henrique Monterio da Silva, em seu interrogatório na fase policial, mencionou ser usuário de drogas há cinco anos, fazendo uso de maconha e cocaína. Negou qualquer envolvimento com o tráfico. Em juízo, relatou que estava descendo na avenida e já fazia uso de drogas de longa data. Estava tendo uma festa, e lá faria uso da droga. Não disse que iria vender a droga. Disse que a droga era para ele usar. Na mão, estava seu celular e sua carteira. Quando foi retirar a CNH de dentro da carteira, a droga caiu. O dinheiro era proveniente do seu trabalho. Havia comprado a droga na mesma data.

Com isso, restou evidente que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, quatro papérols de cocaína. O cigarro de maconha foi por ele próprio parcialmente consumido, o que afasta o tráfico em relação a tal droga.

O réu não trouxe qualquer elemento concreto de sua versão de que é mero usuário de mais de um tipo de entorpecente. Ao contrário, rumava para local em que ocorria uma festa, quando é comum o consumo de entorpecentes pelos frequentadores.

Soma-se a isso a menção de que havia notícias nos meios policiais, por usuários e pela polícia civil, de que o réu estava destinado a traficar na pacata Iacri.

Os relatos e testemunhos dos policiais são firmes, coesos e dignos de

credibilidade. Não há qualquer indicativo ou suspeita de que teriam motivos ou intenção de imputar ao réu conduta que não praticou. São servidores no bom e fiel exercício da missão de reprimir e prevenir a criminalidade.

No mais, a condição de usuário não inibe a traficância.

Para que a conduta seja desclassificada para o delito de porte ilegal de substância entorpecente é preciso prova segura da exclusividade do porte para consumo próprio, o que, no caso, inexistente.

Nesse sentido: "Entorpecente - Tráfico - Desclassificação para uso indevido Inadmissibilidade se ausente a prova da exclusividade do uso próprio" (RT 710/325). No mesmo sentido: "Entorpecentes - Tráfico - Configuração - Autoria e materialidade demonstrada - Prova - Depoimento de policiais - Validade - Desclassificação para a figura do artigo 16 da Lei de Tóxico - Inadmissibilidade - Pequena quantidade - Irrelevância - Modo de acondicionamento e circunstâncias do flagrante, decorrente de denúncias anônimas, que revelam o fim de comércio - Apelo improvido" (Apelação n.º 269.436-3 - Relator Desembargador Passos de Freitas - j . 01-06-1999). "A pouca quantidade da substância apreendida não afasta a possibilidade de tráfico" (RF 290/335).

Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. Neste sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido." (RT 729/542). "Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (RT 714/357). "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663) - (TJ/SP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0005372-64.2011.8.26.0156, Rel. Des. Sérgio Coelho, v.u., julgado em 21.02.2013).

Tampouco se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal.

De rigor, portanto, a condenação do réu por infringência ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, é o caso de reconhecer o tráfico privilegiado, benefício positivado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

O agente é primário, não ostenta maus antecedentes e não há qualquer sinal de que se dedique a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa, de maneira que faz jus ao reconhecimento da benesse em tela.

No tangente ao patamar de diminuição da pena, malgrado o § 4.º do art. 33 da Lei

Antidrogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração redutora, a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram a compreensão de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado balizam o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 -, servirão para a escolha do quantum da redução. Considerando que foi apreendida quantidade não tão portentosa de drogas e que não há nenhuma informação nos autos a desabonar a personalidade e a conduta social do réu, reputo adequado e proporcional a redução da pena no patamar máximo (2/3). Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Recurso objetivando a aplicação do redutor no grau máximo e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório coeso. Confissão. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta reparo. Condições pessoais favoráveis que comportam a incidência do redutor no grau máximo, a fixação do regime aberto, que melhor se adequa às finalidades preventiva e retributiva da pena, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500290-05.2020.8.26.0530, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 16.03.2021); e

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Primariedade. Redutor legal específico. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Regime prisional inicial. Regime aberto. Tratando-se de traficância não especialmente admirável de 160,6 gramas de drogas ilícitas, posto também praticada por agentes primários que não ostentam maus antecedentes, admissível o deferimento da assistência máxima do redutor específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com a substituição por restritivas de direitos das penas privativas de liberdade que, se o caso, haverão de ser inicialmente cumpridas no regime prisional aberto. (TJSP, Apelação Criminal nº 1508466-06.2020.8.26.0228, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, e não descortinadas causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é medida de rigor.

Passo a dosar as penas aplicáveis a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias discriminadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade e a variedade não exorbitantes de drogas não ensejam maior reprovação penal, e não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente. Já analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é inerente à espécie; o réu é primário; as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são próprios do tipo penal, não justificando maior reprimenda.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a penabase no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, concorre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual minoro a pena em 2/3 (dois terços) na esteira do acima explanado -, e, à míngua de causas de aumento, torno-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.700/MG, reafirmou o entendimento gizado de forma incidental pelo Plenário, no julgamento do HC 111.840/ES, de que é inconstitucional o art. 2º, § 1º, da lei 8.072/1990:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, da LEI 8.072/1990.

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.

A dizer: a gravidade abstrata do tráfico de drogas, por si só, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo compreensão que está em consonância com as Súmulas nºs 718 e 719 do STF.

Mais recentemente, sufragando a posição consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do HC nº 596.603-SP, publicado em 22.09.2020, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de João Faustino Neto, condenado como incurso no art. 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedeu ordem individual e coletiva, constando da parte dispositiva:

1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena.

2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto.

3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente.

4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

A Corte Superior de Justiça estabeleceu diretrizes a serem observadas pelos juízes e tribunais de todo o País, dentre as quais:

2.b. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em regime inicial semiaberto, desde que por motivação idônea, que não derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador (art. 33 c/c art. 59 do Código Penal e art. 42 da LAD)

2.c. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal (e ante o afastamento, por ser inconstitucional, da vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, ex vi da Resolução nº 5 do Senado Federal, decorrente do julgamento do HC 97.256, pelo STF).

Nessa ordem de ideias, fixo o regime aberto para início do resgate da pena corporal, porquanto inferior ao patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, e haja vista que o réu não é reincidente (art. 33, § 2º, "c", do Código Penal), sendo favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, sempre do Código Penal). Preenchidos os requisitos dispostos nos incisos do art. 44 do Código Penal (pena concreta inferior a quatro anos; crime não cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa; réu não reincidente em crime doloso; e suficiência e adequação da substituição da pena corporal, diante das circunstâncias judiciais, para atingir as finalidades da sanção), substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (§ 2º do mesmo artigo), consistentes em: (i) prestação pecuniária, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos à época dos fatos, a serem depositados, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, em favor de instituição designada pelo Juízo da Execução Criminal (art. 45, § 1º, do Código

Penal); e (ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, § 3º, do Código Penal), em instituição a ser definida também em sede de execução penal.

Substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de: (a) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, que ora substituo por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em (a.1) prestação pecuniária, no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos à época dos fatos, e (a.2) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma da fundamentação; e (b) 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Apenado com sanção corporal a ser inicialmente cumprida em regime aberto, devidamente substituída por medidas alternativas, cenário incompatível com a prisão preventiva (vide, por todas, a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado - 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 792, encampada pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no Informativo nº 554 da sua jurisprudência). O réu permaneceu solto durante o processo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Decreto, ainda, nos termos do disposto no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, a perda dos valores monetários apreendidos em favor do FUNAD. Oficie-se, pois, informando a decretação do perdimento dos bens referidos. Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração caso ainda não tenha sido realizada.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do patrono nomeado, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

1. Notifique-se o condenado para o pagamento de multa no prazo de 10 dias, art. 50 do CP.

2. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.

3. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe. Comunique-se à vítima do teor da presente, na forma do art. 201, § 2º, do CPP.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Registre-se e Cumpra-se.

Bastos, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA